차별과 계약의 자유

고용에서의 인종차별 금지법의 철학적·경제적 기초

Samantha A. Besson

번역 정리본

원문: “Discrimination and Freedom of Contract”
International Journal of Discrimination and the Law, 1999, Vol. 3, pp. 269–297

주: 본문은 한국어로 번역했고, 주석·참고문헌은 정확한 서지 정보 보존을 위해 원문 표기를 유지했습니다.

사만다 A. 베송(Samantha A. Besson)
프리부르 대학교(스위스)

초록

이 글의 목적은 계약 당사자의 근본적인 사적 자율성과, 당사자가 차별받지 않을 권리 사이에 존재하는 겉보기의 대립을 해명하고, 차별금지법의 정당성을 철학과 경제학의 관점에서 기초 짓는 데 있다. 이러한 논쟁을 다시 불러내는 이유는 최근 '법과 경제학' 진영의 일부 학자들이 차별금지법을 비판하고 있으며, 특히 리처드 엡스타인(Richard Epstein)의 *Forbidden Grounds*가 그 대표적인 사례이기 때문이다. 효율성 중심의 논의에서는 실제로 차별금지법에 의해 근본적으로 침해되고 있다고 재평가되는 것은 오히려 '계약의 자유' 원칙이다.

이 논문은 첫째, 가능한 철학적 기초를 검토하면서 엡스타인의 파생적 자유지상주의에는 설득력이 없음을 보이고, 가드너(John Gardner)의 자율성 기반 완전주의를 지지한다. 둘째, 차별금지법의 효율성 기반 정당화 가능성을 제시하면서, 차별금지법이 시장 과정의 진행을 앞당김으로써 효율적인 결과를 낳을 수 있다고 결론짓는다. 최종적으로 이 글은 차별금지 정책과 계약의 자유를, 시장과 사회 양쪽에 민감한 계약 이론, 곧 계약의 자유를 자율성에 근거한 것으로 이해하고 따라서 차별금지 원칙의 존중을 조건으로 삼는 '사회적 시장 이론(Social Market Theory)' 안에서 조화시키고자 한다.

서론

이 글의 목적은 고용계약에서의 인종차별이라는 오래되었고도 여전히 논쟁적인 문제를 해명하는 데 있다. 한편에는 계약 당사자의 근본적인 사적 자율성, 즉 고용계약을 체결할 자유 혹은 체결하지 않을 자유가 있고, 다른 한편에는 어느 당사자도 차별받지 않고 동등한 존재로 대우받을 권리가 있다. 차별금지법은 필연적으로 계약의 자유, 더 넓게는 자유권과 충돌한다. 전자가 개인 자율성의 영역을 만들어낸다면, 후자는 그 영역 안으로 개입하기 때문이다.

어떤 의미에서 보면 모든 계약행위는 차별을 포함한다. 누군가 특정인과 계약을 맺기로 선택하면, 동일한 조건으로 다른 모든 사람과 동시에 계약할 수는 없기 때문이다. 그러나 시장에서의 이런 종류의 '내재

적 차별(endemic discrimination)'은 계약의 자유가 낳는 무해한 결과이므로, 이 글의 관심사는 아니다. 여기서 다루려는 것은 보다 특정하고 악의적인(invidious) 차별이며, 이하에서 '차별'이라 할 때는 이 의미를 가리킨다.

악의적 차별은 일반적으로 인종과 같은 귀속적 특성에 기초한다. 그러나 무엇이 이런 차별 사유를 '비합리적'인 것으로 만드는지는 극히 논쟁적이다. 예컨대 통계적 차별에서처럼 능력의 신뢰할 만한 지표를 사용하는 경우, 인종과 같은 차별 사유의 사용이 때로는 합리적일 수도 있다. 따라서 먼저, 차별할 이유가 있는 것처럼 보이는 경우에도 왜 그 이유에 따라 행동하는 것이 잘못인지를 설명해야 한다. 다음으로, 도덕적·철학적 정당화 또는 효율성 기반 논증을 통해 잠재적 계약 상대방의 계약 자유에 가해지는 제한을 정당화해야 한다. 이것이 이 글의 과제다. 사적 영역에서의 강제, 혹은 국가가 사적 자율성을 제한하는 일은 이론적으로 기초지어져야 한다.

이 논쟁을 다시 꺼내는 직접적인 계기는 '법과 경제학' 진영 일부 학자들, 특히 엡스타인의 Forbidden Grounds 가 차별금지법을 새롭게 공격하고 있기 때문이다. 이들에 따르면, 사적 영역에 남아 있는 차별은 정당하게 제한되지 않는 계약 자유의 표현이며, 경제적 의미에서 종종 합리적이고 효율적이다. 그 결과 차별금지법은 시장 경쟁을 왜곡하고, 심지어 차별 피해자들에게 부정적이고 역설적인 효과를 낳기도 한다. 엡스타인은 도발적으로 시민권법 제 7 편(Title VII)과 '제국주의적' 사적 차별금지법의 폐지까지 주장한다.

효율성의 언어로 이루어진 이러한 비판에서 실제로 핵심이 되는 것은, 차별금지법 때문에 '계약의 자유' 원칙이 심각하게 침해된다는 주장이다. 얼핏 보면 차별 논쟁에서 계약의 자유가 다시 전면에 등장하는 것은 다소 어색해 보일 수 있다. 하지만 이는 영미 법질서에서는 스위스와 같은 일부 대륙법 질서와 달리 차별금지법이 1960 년대에 본격적으로 발전하던 동안 계약의 자유 개념은 쇠퇴하고 있었고, 최근의 경제학적 비판이 제기되기 전까지는 양자의 관계가 정면충돌하는 것으로 거의 인식되지 않았기 때문이다.

계약의 자유는 개인이 계약을 체결할지 여부를 스스로 선택할 수 있어야 한다는 뜻이다. 그러나 이 개념은 19 세기 자유방임과 개인주의적 정의관, 교환질서 속에서 처음 등장한 이후 크게 변화했다. 19 세기 후반 이래 계약의 자유는 지속적으로 제한되어 왔고, 차별금지법도 그러한 제한 중 하나다. 더 나아가 '사회적 시장 이론'과 같은 현대 계약이론은 계약을 단지 사적인 선택의 산물이 아니라, 시장에 참여하는 개인에게 법이 구조화된 의무를 부과하는 장치로 이해하며, 계약의 자유 자체도 자율성 개념을 새롭게 해석한 형태로 파악한다. 그럼에도 엡스타인과 같은 일부 현대 저작은 1980 년대 이후에도 여전히 19 세기적이고 개인주의적인 계약 자유 개념을, 다만 경제학과 자유지상주의 법사상에서 가져온 새로운 가치와 개념으로 재포장하여 사용한다. 이 글의 문제의식은 바로 그 지점에서 출발한다.

이 글은 먼저 차별금지법의 철학적 기초를 검토하고(I), 다음으로 미국 시민권법 제 7 편(1964 년 제정, 1972 년 개정)과 영국 인종관계법(Race Relations Act, 1976)과 같은 차별금지법의 효율성 기반 정당화를 논의한다(II). 그리고 마지막으로 시장과 사회 모두에 민감한 계약이론 안에서 차별금지 정책과 계약의 자유를 화해시키는 것을 목표로 한다.

I. 차별금지법의 철학적 기초

A. 일반론

차별금지법의 정당화를 시도할 때 가장 어려운 점 중 하나는 국가가 어떤 사유에 근거한 차별을 금지할 수 있는가뿐 아니라, 누구에게 그러한 차별을 금지할 수 있는가 하는 점이다. 국가 자신이 동등한 배려와 존중의 의무 및 비차별 정책에 구속되는지 여부도 정치이론마다 다르지만, 시민들 상호 간의 차별을 금지할 이유를 제시해야 할 때 문제는 한층 더 복잡해진다.

동등한 존중과 배려를 시민 개인에게 곧바로 부과할 수 있는 일반 의무로 보는 것은, 사적 자율성, 자유, 개인의 판단과 선호의 영역을 비워 버릴 위험이 있다. 시민들이 서로에게 국가가 모든 시민을 대하듯 동등한 존중과 배려의 의무를 진다고 주장하는 것은 공화주의적 시민성 이론을 도입하는 셈이며, 이는 결국 국가가 시민의 성격, 도덕, 신념 같은 사적 영역에 개입하여 '좋은 삶'에 대한 특정 비전을 강요하는 완전주의(perfectionism)로 이어질 수 있다. 이는 국가는 무엇이 '옳은가'를 규정할 수는 있어도 무엇이 '좋은가'를 강요해서는 안 된다는, 자유주의적·자유지상주의적 국가중립성 원칙과 충돌한다.

이 글은 차별할 자유에 대한 국가의 개입을 정당화하는 방식에서 서로 다른 두 입장을 대표하는 저자, 즉 극단적 자유지상주의에 가까운 리처드 엡스타인과 보다 완전주의적인 존 가드너의 견해를 검토한다.

B. 엡스타인의 자유지상주의

엡스타인은 도발적이고 논쟁적인 저서 *Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Law*의 서두에서 두 개의 도입부를 통해 자신의 차별금지법 비판을 떠받치는 철학적·정치적·경제적 기초와 인종차별의 법사를 제시한다.

그의 개념적 도입은 효율성에 관한 경제이론과 차별금지법 분석에 기대어 계약 자유 체제를 옹호한다. 엡스타인에 따르면 차별 피해자에게 더 나은 기회를 찾게 해 주고, 경쟁을 통해 부당한 차별을 시장에서 몰아내는 것은 차별금지법이 아니라 '평등한 계약 자유'다. 반면 차별금지법은 개인의 자유에 대한 부당한 국가 개입이며, 경쟁시장에서 계약의 자유가 대부분의 비효율적 차별을 제거하고 합리적 차별은 남겨 두며 부를 극대화할 수 있음에도, 이를 방해하여 비효율적이고 비용이 큰 결과를 낳는다.

그에게 국가 개입은 계약 자유라는 중심권리를 적극적으로 보호하는 범위, 즉 국가가 후원하는 차별을 제거하고 시장이 사기와 강제로부터 정상적으로 작동하도록 보장하는 수준에 머물러야 한다. 사적 차별의 금지까지 나아가는 것은 허용되지 않으며, 따라서 사적 차별을 향한 모든 국가 개입은 위헌적이라는 것이다. 역설적으로 그의 이론은 사회 전체의 선호 충족을 극대화하는 일종의 공리주의에도 기대고 있다.

엡스타인의 기본 원리는 다음과 같이 요약할 수 있다. 그는 우선 법이 사적 강제를 통제해야 한다는 통찰과, 정부 기능을 최소화하는 자유지상주의적 관점을 재확인한다. 그리고 분배정의와 '자연적' 취득 규칙을 통해 외적 대상의 소유권을 개인에게 귀속시키고, 그렇게 형성된 원초적 권리가 자발적 거래를 통해 변형·재조합될 수 있다고 본다. 이는 노직의 역사적 자격이론과 자유로운 처분 개념을 계승하는 것이다.

이어 그는 노동에 대한 자기소유(self-ownership) 원리로 이동한다. 이 원리는 동의에 기초한 자발적 거래를 가능하게 할 뿐 아니라, 자율성 논거를 현대 경제학의 사회후생 및 파레토 효율 개념과 가장 잘 연결해 준다고 본다. 노동시장에서는 이것이 계약 자유의 초석이다. 시장실패가 발생하는 드문 경우에만 정부는 재산권과 계약권의 집행을 넘어 개입할 수 있다. 공공재 제공을 지지하는 경우에도 그는 정부 활동으로 침해되는 권리에 대해 정당한 보상이 지급되어야 한다고 본다. 그래서 그의 자유지상주의적 보통법 체제는 자연상태보다 파레토 우월한 자원배분을 달성한다고 주장된다.

엡스타인에게 고용시장의 사적 질서와 노동·재산에 대한 분권적 통제는 모두의 참여를 촉진한다. 그는 국가 개입이 없는 경쟁적 고용시장을 이상화하며, 그 시장에서는 계약 자유가 완벽하게 들어맞는다고 본다. 효용 극대화와 부의 극대화의 차이는 크게 문제 삼지 않는다. 이런 '자연법적·보통법적' 원리의 완결성 안에서 차별금지법은 부당한 공격으로 간주된다.

그의 이론에서 자유로운 진입(free entry)은 경쟁적 고용시장의 핵심 요소가 된다. 그런데 사실상 그가 반경쟁적 진입 제한을 비난하는 논리는, 역으로 차별금지법을 친경쟁적 조치로 옹호하는 데도 쉽게 쓰일 수 있다. 그럼에도 엡스타인은 사적 차별을 '강제'와 동일시하는 것을 거부한다. 그의 말에 따르면, 강제는 타인을 최악의 상태에 노출시키고 사기는 타인이 속임수를 써서 가져가려는 것을 경계하게 만들지만, 차별하는 사람은 단지 특정인과 거래를 거부할 수 있을 뿐이며 그에게 힘을 행사하는 것은 아니라는 것이다. 그래서 차별의 피해자는 특정 거래의 이익을 얻지 못하거나 심리적 상처를 입더라도, 강제의 피해자와는 달리 자신의 초기 권리묶음은 그대로 보존한 채 다른 계약 상대를 찾을 자유를 가진다고 그는 말한다. 더 나아가 일부 고용주가 소수자를 고용하지 않을수록 다른 고용주에게는 소수자를 고용할 유인이 커지고, 경쟁시장이 차별을 없애지 못하는 경우라면 그 차별은 효율적이고 합리적이라는 결론까지 내린다.

그러나 엡스타인의 철학적 지향은 쉽게 정리되지 않는다. 그의 법사상이 자연권적 자유지상주의에서 제한정부형 공리주의로 이동했다는 평가도 있고, 여기에 계약 자유에 대한 강한 집착이 더해진다. 이 세 경향은 모두 사적 시장에 대한 개입에 회의적이며 경제이론에 대한 의존을 공유한다. 하지만 한편으로 그의 집단적 사회후생 극대화와 선호충족 중심 공리주의는 절대적 자율성과 개인권리를 강조하는 자유지상주의와 양립하기 어렵다. 시장의 유효성과 정부의 무능에 관한 강한 경험적 주장도 이 긴장을 해소하지 못한다. 다른 한편으로 사회후생 증진에서 정부의 역할을 지나치게 제한하는 그의 주장 역시 그가 말하는 만큼 충분히 공리주의적이지 않다. 그는 자유지상주의적 가치에 근본적으로 헌신한다고 말하면서도 시장 결과의 긍정성에는 집착하고, 역사적 해악과 그 교정 문제는 거의 무시한다. 재분배 목적에 대한 그의 대답은 차별금지법이 그저 '비효율적' 수단이라는 것이다.

더구나 엡스타인의 '평등한 계약 자유' 개념은 실제로는 분배적 전제를 깔고 있으면서도 이를 인정하지 않는다. 그는 기회균등 원칙과 분배정의를 원용하지만, 사람들의 출발선이 다르다는 점을 고려하는 다른 자유주의적 기회균등 논의는 외면한다. 대신 그는 모든 선호를 동등하게 대우해야 하며 차별하려는 선호도 좌절되어서는 안 된다는, 상반된 공리주의 원리를 일관성 없이 끌어들인다.

이러한 비판에 대해 엡스타인은 여전히 혼합적 철학 기초를 유지한다. 법적 권리는 사회 전체의 효용 수준을 극대화하기 위해 인간이 창조한 것이며, 공권력의 사용은 두 가지 경우에만 정당하다고 본다. 첫째, 사기와 강제 같은 사적 폭력을 통제할 때, 둘째, 자발적 합의가 거래이익을 충분히 실현하지 못하도록 막는 거래비용 장벽을 제거할 때다. 그리고 어느 경우든 국가 개입 비용은 방지되는 해악보다 커서는 안 된다. 그런데 엡스타인은 고용관계를 본래적으로 경쟁시장에 속하는 것으로 보고, 그 시장이 자연스럽게 최선의 결과를 낳는다고 보므로 국가 개입의 정당화는 사실상 불가능해진다.

엡스타인은 자신의 기본 틀을 자유지상주의가 아니라 공리주의라고 주장한다. 1 차적 수준에서는 개인 자율성과 상호교환을 법체계의 최고 가치로 취급하지 않기 때문이다. 그러나 힘, 사기, 독점이 제거된 뒤에야 개인들 사이의 차별금지법 논의가 가능하다고 보는 순간, 실제 사안 판단은 다시 강한 재산권과 계약 자유, 그리고 국가 개입이 초래하는 사회적 손실을 강조하는 '파생적 자유지상주의'의 2 차 틀로 넘어간다. 적극적 의미의 계약 자유와 소극적 자유지상주의는 모순되지 않는다고도 그는 주장한다. 모든 자유지상주의자는 계약 자유를 지지하며, 힘과 사기를 금지하는 것은 외부에서 법적 의무를 강요하는 경우만을 문제 삼는다는 것이다.

엡스타인의 이론은 역사적 부정의를 무시한다는 점에서 비역사적일 뿐 아니라, 사회이론과 법이론 모두 충분한 역사적 기반을 결여했다는 점에서도 비역사적이다. 첫째, 그는 미국 인종차별의 역사를 시장에 대한 자신의 신념을 뒷받침하는 방향으로 편의적으로 재해석한다. 그에 따르면 시민권법 제 7 편은 과거의 인종차별적 국가권력을 부수고 경쟁시장을 창출하는 데는 필요했지만, 이제는 오히려 자의적 차별을 막을 수 있는 자유롭고 효율적인 시장을 속박하고 있을 뿐이다. 그러나 그는 북부의 경쟁시장에도 차별이 존재했다는 사실, 그리고 시장을 왜곡한 사적 폭력과 인종주의적 규범, 사회적 압력과 제재 메커니즘을 외면한다. 둘째, 그의 법이론은 구식이다. 그는 여전히 Lochner 사건이 보여 주는 19 세기 자유주의적 보통계약법 원리에 기대고 있다. 또한 시민권을 민사능력과 결사의 자유에 밀접히 연결된 19 세기 협의의 개념으로만 이해하기 때문에, 특정 악의적 선호를 표현하는 계약을 문제 삼는 차별금지법이 그의 법이론에 잘 들어맞지 않는 것은 오히려 당연하다.

결국 엡스타인은 자유시장을 정당화하는 서로 대립하는 두 이론적 근거 사이를 기회주의적으로 오가며, 이용 가능한 경험적 증거를 희생시키는 편향된 법경제학을 강조한다. 이 결함은 그의 이론 전반의 신뢰성을 크게 약화시키며, 차별금지법에 대한 폭넓은 사회적 합의에 맞서 그의 주장을 평가하기 어렵게 만든다. 그는 계약 자유를 시민권법의 기준으로 삼을 만한 진지한 규범적 토대를 제시하지 못하고, 사회가 도덕을 입법할 권리가 있다는 생각을 충분히 반박하지도 못한다.

C. 가드너의 자율성 기반 완전주의

존 가드너의 차별금지법 연구는 흔히 '초기 가드너'(1992 년까지)와 '후기 가드너'(1996 년 이후)로 나눌 수 있다. 그런데 많은 문헌은 여전히 초기 가드너의 견해를 부정확하게 인용한다. 그 이유는 앞서 말했듯, 한편으로 인종차별이 왜 잘못인가를 설명하는 문제와, 다른 한편으로 그 잘못된 차별을 방지하기 위해 법을 사용하는 것이 왜 정당한가를 설명하는 문제를 분리하지 못했기 때문이다. 이 글은 둘을 구분한 뒤, 특히 후자의 문제에 초점을 둔다.

사적 영역에 법이 개입해 사람들로 하여금 서로를 동등하게 대우하도록 요구하는 것이 정당한가라는 문제 앞에서, 가드너는 자유사회에서 법의 한계를 정하는 두 가지 상이한 관점 가운데 하나를 선택해야 했다. 하나는 법의 역할을 개별 피해자에 대한 해악 방지에 한정하는 관점이고, 다른 하나는 사회 전체에서 정의가 실현되도록 하는 것이 법의 과제라고 보는 관점이다. 이 둘은 서로 교차한다. 해악은 없지만 불의한 경우도 있고, 불의는 아니지만 해로운 경우도 있기 때문이다. 그래서 어떤 이들은 이 둘을 결합하려 하지만, 가드너는 자유사회에서 법적 정당성의 한계를 둘러싼 진정한 경쟁 관점으로 본다.

초기 가드너의 혼동은 바로 여기서 시작되었다. 그는 법의 정당성에 관한 해악 기반 접근과 정의 기반 접근의 경쟁을, 차별이 왜 잘못인지에 대한 두 설명, 즉 시정적 불의(corrective injustice)와 분배적 불의(distributive injustice)의 경쟁과 혼동했다. 그 결과 직접차별은 해악 원칙에 따라 금지되어야 할 시정적 불의로, 간접차별은 정의 원칙에 따라 금지되어야 할 분배적 불의로 각각 대응시켰다. 그렇게 되면 법적 정당성의 두 원리가 경쟁하듯, 차별의 위법성 설명에서도 시정적 관점과 분배적 관점이 정면충돌하는 것처럼 보이게 된다. 가드너는 나중에 이 입장을 수정한다.

후기 가드너는 어떤 행위가 잘못인 이유는 하나로 통일될 필요가 없다고 본다. 분배정의의 이유, 시정정의의 이유, 그 밖의 정의와 무관한 이유들이 함께 작용해 하나의 행위를 잘못되게 만들 수 있다. 그러므로 차별이 왜 잘못인지에 대한 도덕적 설명이 다층적이라고 해서 문제될 것은 없다. 중요한 것은, 어떤 구조를 취하든 그러한 도덕적 의무가 자유사회에서 법의 정당성 한계를 통과할 수 있어야 한다는 점이다. 따라서 초기 가드너처럼, 자신이 넓은 의미의 해악 원칙에 따라 차별금지법을 정당화한다고 해서 차별이 분배적 불의라는 생각 자체를 버릴 필요는 없다.

가드너의 최근 작업은 특히 자율성에서 파생되는 개인의 정체성을 이유로 한 차별의 잘못에 주목한다. 자율적 삶이란 가치 있는 여러 선택지 가운데서 실제로 가치 있는 선택들을 연속적으로 수행하며 살아가는 삶이다. 여기서 핵심은 선택의 자유가 무제한이어야 한다는 것이 아니라, 충분히 넓고 가치 있는 선택지의 범위가 개인에게 주어져야 한다는 점이다.

초기 가드너는 자유주의적 자율성 개념을 통해 차별의 시정적·분배적 정의 설명을 중재하려 했고, 후기로 가면서는 국가가 특정한 가치 있는 자유, 즉 자율성의 문화를 보호하고 촉진해야 한다는 보다 분명한 입장으로 나아간다. 그는 라즈(Raz)의 자율성 개념을 따라, 국가가 사람들의 자율성을 약화시키는 행위를

막을 뿐 아니라 자율성을 향상시키는 선택지와 기회를 마련하도록 강제할 수도 있다고 본다. 다시 말해, 해악 원칙은 매우 넓게 이해되어야 한다.

이 관점에서 차별금지법은 단지 피해자를 해악으로부터 소극적으로 보호하는 제도가 아니다. 국가는 시민들의 가치 있는 자율성을 증진하는 문화, 즉 관용과 경쟁적 다원주의의 문화를 유지해야 하며, 차별적 구조는 바로 그런 문화를 배반한다. 왜냐하면 그것은 사람들이 누려야 할 가치 있는 선택지의 범위를 줄이기 때문이다. 자율성은 무제한적인 개인 선택을 뜻하지 않는다. 오히려 공유된 문화적 가치들의 저장소이며, 차별금지법은 그 가치를 실현하기 위한 제도다.

따라서 차별금지법과 그 집행 방식은 하나의 목적, 즉 시민의 가치 있는 자율성을 향상시키고 그들이 공유하는 문화의 이상을 구현하는 목적을 가진다. 이 비개인주의적 자율성 이론에서는 국가는 시민들에게 가치 있는 충족의 조건을 제공하는 고유한 프로젝트를 갖고 있으며, 그래서 차별을 금지해 개인의 자율성을 파괴하는 행위를 막을 뿐 아니라, 자율성을 향상시키는 특정 행위를 적극적으로 요구할 수도 있다.

가드너는 이러한 자율성 기반 관점을 발전시켜 사적 영역과 공적 영역의 구분 자체를 문제 삼는다. 어떤 관계가 공적 규제로부터 면제된 '사적 영역'에 속하는지 여부는 늘 논쟁적이다. 중요한 것은 차별자가 맡고 있는 사회적 역할이다. 예컨대 고용주는 자신의 종업원에 대해 특정한 책임을 지니며, 바로 그 책임 때문에 어떤 선호는 정당한 도덕적 공간을 넘어서게 되고, 따라서 부적절한 사유에 근거한 차별은 허용될 수 없다.

겉으로 보기에는 고용관계와 같은 '시장관계'는 공적 영역에 속하므로 차별금지법이 적용되는 것이 당연해 보인다. 그런데 판례는 때때로 차별을 정당화하는 '경제적 요인'을 다른 기준이 미치지 못하는 독립 영역처럼 취급해 왔다. 가드너는 이에 반대한다. 차별금지법은 시장이 실패할 때만 뒤에서 보완하는 소극적 규제가 아니라, 시장 그 자체를 자유사회 안에 머물게 하기 위해 선제적으로 작동하는 규범적 장치다. 인종 차별이 시장에서 때로 합리적일 수 있다는 사실은 오히려 시장이 사회 전체의 자율성이라는 기준에 의해 제한되어야 함을 보여 준다. 따라서 시장거래 주변에든, 사적 가정과 클럽 주변에든, 차별금지법은 더 이상 자유주의적 '사생활의 장벽' 앞에서 멈춰 설 이유가 없다.

요컨대 가드너의 자율성 이론은 자유사회에서 차별금지법이 왜 정당한지 설명하는 데 매우 강력한 열쇠를 제공한다. 이 이론은 논의를 해악 원칙과 정의 원칙의 이분법에서 끌어내며, 넓은 의미의 해악 원칙에 기대어 국가가 사적 영역에서도 차별에 대해 예방적이고 적극적으로 개입할 수 있음을 정당화한다.

II. 차별금지법의 효율성 기반 정당화

A. 효율성 분석의 모형

효율성은 법경제학의 핵심 개념 가운데 하나다. 그것은 어떤 상태에서의 총편익과 총비용의 관계를 가리키며, 가치가 극대화되는 자원배분 상태를 의미한다. 이 글은 효율성을 칼도어-힉스(Kaldor-Hicks) 의미에서 사용한다. 즉, 자원배분의 변화로 생기는 가치 증가분이 충분히 커서 손해를 입는 사람들에게도 완전한 보상이 가능하다면 효율적이라고 보는 입장이다.

보수적 법경제학자들은 대체로 다음과 같은 방식으로 차별금지법을 비판한다. 규제가 없는 경쟁적 노동시장은 효율적이고, 효율성은 바람직한 정치적·사회적·경제적 편익을 가져오며, 차별금지법은 노동시장을 제약하므로 비효율적이고 역효과를 낳는다는 것이다.

그러나 진정으로 기능하는 경쟁적 노동시장이라는 전제 자체가 비현실적이라는 점은 곧 드러난다. 노동시장은 불확실성, 정보의 제한, 매몰비용 같은 구조적 불완전성을 지니며, 신고전파 균형모형이 상정하는 완전경쟁시장과 같을 수 없다. 따라서 그것을 '고용계약의 보통법'이 상정하는 경쟁 이상에 맞추어 복원한다는 생각은 성립하기 어렵다. 더구나 규제 없는 노동시장은 임금과 노동조건을 노동자의 상대적 생산성과 적절히 연결하기보다는, 오히려 왜곡된 노동기준을 만들어 낼 수 있으며, 이는 더 큰 평등을 보장하는 국가 개입을 통해서만 교정될 수 있다.

경쟁시장 가정에서 역으로 도출되는 것은, 독점이나 파생적 가격차별처럼 시장실패가 존재하는 경우에는 법 개입이 정당화된다는 점이다. 따라서 규제는 시장이 갖고 있다고 주장되는 '반차별적 측면'이 실제로 작동하지 못하게 만드는 요인들을 제거하는 방향으로 작동해야 한다. 일부 학자들은 차별이 경쟁시장 안에서도 언제나 일종의 시장실패일 수 있다고 보며, 바로 이 점이 차별금지입법의 일반적 정당성을 뒷받침한다고 주장한다.

B. 차별 제거를 위한 자유시장과 규제의 비교

차별금지법의 효율성을 따지려면, 규제 없는 자유시장에서의 차별 효율성과 국가 규제의 효율성을 비교해야 한다. 차별금지법은 사회적 편익을 낳지만 비용도 발생시킨다. 따라서 핵심은 그 비용을 치를 만한 가치가 있는가 하는 점이다. 이 비용-편익 분석은 경제학이 구분해 온 두 가지 차별 모형, 즉 취향 기반 차별(taste-based discrimination)과 통계적 차별(statistical discrimination)을 중심으로 이루어진다.

1. 규제되지 않은 시장

a. 취향 기반 차별

i. 고용주의 취향

고용주는 지원자의 업무 적합성과 무관한 요소를 기준으로 채용에서 차별할 수 있다. 이것은 특정 집단에

대한 선천적 호오, 즉 '차별 취향'의 표현일 수 있다. 이 경우 소수집단 구성원을 고용할 때 고용주는 자신의 심리적 불쾌감이라는 추가비용을 부담하게 된다. 문제는 이러한 편향이 경제적으로 효율적인가이다.

신고전파 가정에 따르면, 고용주의 적대감에서 비롯된 차별은 장기적으로는 시장에 의해 제거되거나 소수자 임금에 아무 효과도 남기지 못한다. 차별 취향은 비용을 발생시켜 차별하는 고용주를 경쟁상 불리하게 만들기 때문이다.

차별적 고용주에게는 두 가지 선택지가 있다. 첫째, 소수자를 고용하되 심리적 비용을 상쇄하기 위해 그들의 임금을 낮추려 할 수 있다. 그러나 탄력적인 노동시장에서는 이를 완전히 상쇄할 수 없으며, 결국 비차별적 고용주에 비해 자신의 경제적 이윤이 줄어든다. 둘째, 소수자를 아예 채용하지 않고 그들을 완전히 대체할 수 있는 다른 노동자를 찾을 수 있다. 그러나 이 경우에도 경쟁자에게 더 저렴한 노동력을 넘겨주는 셈이므로 역시 불리해진다. 따라서 이런 차별은 해로운 형태로 오래 지속되지 못한다.

그럼에도 불구하고 시장 고유의 불완전성 때문에, 매우 경쟁적인 경제에서도 경제적으로 의미 있는 규모의 잔여적·비효율적 차별이 남을 수 있다는 점은 인정해야 한다.

ii. 동료 노동자의 취향
노동자 자신도 차별 취향을 가질 수 있다. 특정 집단 출신 노동자와 함께 일하기를 거부하거나, 함께 일하는 대가로 임금 프리미엄을 요구할 수 있다. 그러면 편견 없는 고용주라도 해당 집단을 채용하지 않거나, 채용하더라도 추가비용을 줄이기 위해 그들의 임금을 낮추려 할 수 있다.

경쟁시장에서는 장기적으로 노동자들이 경쟁적 임금 수준에서 일자리를 얻기 위해 자신의 취향을 수정할 유인이 생긴다. 하지만 단기적으로는 임금 차이가 있든 없든 기업의 분리를 낳는 바람직하지 않은 경향이 나타날 수 있다.

베커(Becker)의 모형에 따르면, 동료 노동자의 차별 취향은 소수자와 비소수자 간의 임금 격차 없이도 분리된 기업을 낳을 수 있다. 고용주는 통합된 노동력을 쓰면서 발생하는 생산성 저하나 다수집단 노동자의 임금 인상 요구를 피하기 위해 통합 노동력을 채용하지 않게 된다. 이 경우 시장은 '비차별적' 균형에 도달하더라도, 그것은 '분리하되 평등하다(separate but equal)'는 식의 분리 균형일 뿐이다. 더구나 소비자들도 비슷한 차별 취향을 가질 수 있어 소수자 기업을 외면할 가능성이 크므로, 장기적 균형 자체가 위협받는다. 다른 모형들은 소수자와 비소수자 노동력이 완전대체재가 아니라는 점, 노동자에 대한 다양한 투자 때문에, 통합된 노동력 속에서도 임금 차별이 지속될 수 있다고 예측한다.

장기적으로는 경쟁이 이러한 차별 형태를 밀어낼 경향이 있다. 통합 노동력을 고용하는 비용이 더 크더라도, 분리된 노동력만 사용하면 가치 있는 투입을 놓쳐 손해를 볼 수 있기 때문이다. 또한 차별의 부정적 결과에 대한 사회적 민감성이 높아지면 시장선택에 영향을 미쳐 동료와 소비자의 취향에 기초한 차별을 약화시킬 수도 있다. 하지만 정보비용 때문에 고용주가 생산성 저하의 정확한 원인을 파악하기 전까지는 차

별이 지속될 수 있다. 이 점에서 규제는 시장이 올바르게 작동하는 속도를 앞당기는 유익한 역할을 할 수 있다.

iii. 소비자의 취향

고용주의 상품이나 서비스를 구매하는 소비자 역시 차별 취향을 가질 수 있다. 이 경우 고용주는 차별적 소비자의 선호에 맞추기 위해 노동력을 조정하려 할 수 있다. 소수자를 고용한 기업과는 거래하지 않으려는 소비자들 때문에 추가비용이 발생하기 때문이다.

소비자의 적대감에서 비롯된 차별은 경쟁이 자동으로 줄여 주지 않는다. 한편으로는 소수자 임금을 낮추는 방향으로 작용한다는 모델이 있고, 다른 한편으로는 그렇지 않다는 모델도 있다. 베커의 모형에 따르면 충분한 수의 비차별적 소비자가 존재하는 한 모든 기업은 판매를 계속할 수 있으므로, 시장은 다시 임금 격차 없는 분리시장으로 수렴할 수 있다. 하지만 이는 장기적으로도 인종적 계층화를 강화한다. 다른 모형에 따르면 상당수의 차별적 소비자가 존재하면, 비차별적 소비자도 충분히 있더라도 소수자 임금은 낮아질 수 있다. 고용주는 차별적 거래 상대를 잃는 비용과 비차별적 소비자를 새로 찾는 비용을 소수자 노동자에게 전가하려 하기 때문이다.

결국 소비자 취향에 기반한 차별에서는 장기 균형조차 차별적일 수 있다. 시장은 분리된 시장 또는 임금 차별을 낳을 수 있고, 따라서 규제는 차별적 소비자의 후원을 얻기 위한 경쟁 자체를 막는 친경쟁적 수단으로 필요하다.

b. 통계적 차별

고용주는 직무 수행능력을 평가할 때 관련 정보가 필요하다. 그러나 정보는 불완전하고 획득 비용도 크며, 채용·해고 비용도 존재한다. 그래서 고용주는 생산성과 연관된다고 생각되는 눈에 띄는 지표나 대리변수(proxy)를 사용하여 선발비용을 줄이려 한다. 이때 반드시 소수자 집단에 대한 반감이 없어도, '통계적 지표'를 이용해 누가 일을 잘할지를 예측할 수 있다. 여기에는 인종이나 성별처럼 개인이 통제할 수 없는 귀속적 특성(지표, indices)과, 외모처럼 어느 정도 통제 가능한 특성(신호, signals)이 있다.

통계적 차별은 두 경우로 나눌 수 있다. 첫째, 대리변수가 서로 다른 집단의 평균적 특성을 어느 정도 정확하게 포착하지만, 그 특성 분포가 실제로는 상당히 겹치기 때문에 보다 개별화된 판단을 하면 불리한 집단 구성원도 유리한 집단 구성원 못지않게 일을 잘할 수 있는 경우다. 둘째, 대리변수 자체도, 그것이 가리키는 '능력' 개념 자체도 지배집단에 유리하게 편향되어 있는 경우다.

핵심 질문은 이러한 통계적 특성의 사용이 장기적으로 채용 과정의 효율성을 높이는가이다. 경쟁이 통계적 차별에 미치는 효과는, 그것이 실제 생산성 차이를 반영하는지 여부에 달려 있다.

실제 생산성 차이가 없다면, 통계적 차별은 장기적으로 지속되지 않아야 한다. 부정확한 대리변수를 일반화해서 쓰는 것은 기업의 생산성을 떨어뜨리기 때문이다. 그러나 현실에서는 부정확한 정보에 기초한 '오류적 차별'이 지속될 수 있다. 그 결과 소수자 노동자는 인적자본에 대한 투자를 줄이게 되고, 바로 그 때

문에 차별이 나중에는 경제적으로 '합리적'인 것처럼 보이는 악순환이 만들어진다. 즉, 원래는 부정확했던 대리변수가 차별이 낳은 결과 덕분에 나중에는 더 정확해지는 것이다. 이런 악순환을 끊으려면 더 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고, 고용주가 실제로 소수자 노동자를 시험적으로 고용해 보도록 유도해야 한다. 따라서 통계적 차별의 점진적 해소를 시장 순환에만 맡기는 것은 극히 일부 경우에만 가능하며, 차별금지법이 훨씬 더 효율적일 수 있다.

스트라우스(Strauss)는 통계적 차별이 집단 간 실제 생산성 차이를 반영할 때에만 지속된다고 본다. 그러나 이 경우에도 경쟁시장에서 시간이 지나며 그 사용이 줄어들 수 있다. 그 이유는 정확성 때문이 아니라 비용구조의 변화와 새로운 인사평가 기술의 등장 때문이다. 더구나 '인적자본' 논의가 보여 주듯, 생산성 차이 자체도 종종 외생적인 것이 아니라 차별이 낳은 결과다. 통계적 차별과 인적자본 투자 부족이 서로를 강화하는 악순환은, 실제 생산성 차이를 반영하는 것처럼 보이는 통계적 차별조차 장기적으로 사라질 수 있음을 보여 준다.

매킨토시(Macintosh)는 특히 과거에 불이익을 겪어 온 소수자를 채용하는 경우 노동시장이 지속적인 역선택 문제를 겪을 수 있다고 본다. 이때 고용주가 통계적 대리변수에 의존하는 것은 사적으로는 합리적일 수 있다. 그러나 사회적으로는 비효율적이다. 부정확한 대리변수조차 시장에서 무기한 존속할 수 있고, 시간이 지나면 그 부정확성이 현실을 만들어 내어 실제로 더 정확해질 수도 있다. 그 과정에서 소수자의 인적자본 투자를 위축시키고, 결국 소수 노동자의 경제적·사회적 잠재력을 충분히 실현하지 못하게 하는 함정이 형성된다. 따라서 통계적 차별의 사회적 비용은 그 사회적 편익을 초과할 가능성이 크다.

2. 규제된 시장

a. 일반론

차별금지 규제에 대한 비판은 주로 두 가지다. 첫째, 경쟁은 비이윤적 취향 기반 차별을 스스로 제거하므로 규제는 비용 대비 정당화되지 않고 오히려 비효율적이라는 주장이다. 둘째, 잔여적 차별 중 일부는 부의 극대화 기준에서 효율적이므로 이를 금지하는 것은 잘못이라는 주장이다.

규제의 효율성을 둘러싼 핵심 문제는 첫 번째 비판, 즉 시장이 자연스럽게 비차별 균형으로 수렴한다는 생각에 관한 것이다. 과연 차별금지법은 시장의 힘에만 맡겨 두는 것보다 그 균형으로 더 빨리 이동하게 만드는가?

베커와 같은 전통적 효율성론자들은 차별금지법을 비효율적이라기보다 불필요한 것으로 본다. 시장은 이미 스스로 비차별 균형으로 나아가는데, 법은 여기에 사회적·행정적 사중손실(deadweight cost)만 추가한다는 것이다. 소수 노동자의 한계생산물이 그 임금보다 큰데도 그들을 고용하지 않거나, 소수 고객을 상대하지 않는 기업은 이윤을 포기하는 셈이므로 장기적으로 시장에서 밀려난다. 비차별적 기업이 더 낮은 비용과 더 넓은 고객층을 통해 이를 대체한다는 것이다.

하지만 이러한 베커식 모델은 오늘날 더 이상 설득력이 약하다. 첫째, 차별의 원천을 개별 고용주의 사적인 인종혐오로만 파악한다. 둘째, 노동시장을 완전경쟁시장으로 가정한다. 그러나 실제 차별은 사회적·공동체적 차원을 갖고 있으며, 노동시장도 완전경쟁과 거리가 멀다.

도노휴(Donohue)는 경제이론과 합리적 경험적 추론에 비추어 볼 때, 시장을 더 빨리 균형조건으로 이끄는 법은 장기적으로 상당한 순사회편익을 낳을 수 있다고 본다. 그의 분석은 신고전파의 정태적 노동시장 모형과 달리 시민권법 제 7 편을 동태적으로 이해한다. 장기적으로 효율적인 기업은 결국 차별에서 벗어나게 되지만, 기업은 정보를 완벽하게 반영하지 못하고 조정도 더디다. 따라서 법은 차별에 대한 시장 패널티에 법적 패널티를 덧붙여 시장과정의 속도를 높여 줄 수 있다. 비차별적 직장을 더 빨리 만드는 데 드는 비용은 그 편익으로 정당화된다는 것이다.

포스너(Posner)는 법이 균형에 더 빨리 도달하게 만들 수 있다는 점은 인정하면서도, 시장이 결국 같은 결과를 가장 효율적인 속도로 낳을 것이므로 차별금지법은 오히려 '너무 빨리' 차별을 줄여 비효율적이라고 주장한다. 그는 행정비용과 조정비용을 강조하며, 특히 통계적 차별은 이윤극대화적이기 때문에 시장에서 억지로 제거하는 것은 비효율적이라고 본다.

이에 대해 도노휴는, 입법이 없어도 차별기업이 결국 사라진다는 점이 오히려 시민권법 제 7 편을 지지하는 강력한 근거라고 응답한다. 어차피 차별 제거 과정에서 발생할 조정비용은 규제가 있든 없든 언젠가는 발생한다. 차이는 단지 그 비용이 더 이른 시점에 발생하느냐뿐이다. 시장이 스스로 최적 경로를 형성하지 못하는 경직성이 존재하기 때문에, 규제는 바로 그 경직성을 깨는 장치라는 것이다.

엡스타인은 시카고 학파의 정통성을 넘어서, 베커의 전통적 논거와 '법이 차별 제거를 가속화한다'는 주장 모두를 거의 무의미한 것으로 취급한다. 그에 따르면 시민권법 제 7 편 직후 소수자 고용이 개선된 것은 단지 짐 크로(Jim Crow)형 국가 차별이 제거된 결과일 뿐이다. 거래비용이 존재하는 현실 세계에서 경쟁시장은 대부분의 차별을 제거하겠지만, 합리적이고 효율적인 차별은 일부 남게 된다. 그런데 차별금지법은 바로 그런 합리적 차별까지 금지하기 때문에 숨겨진 비용을 만들어 내며, 그래서 폐지되어야 한다는 것이 그의 결론이다.

그러나 차별금지법이 비차별 균형을 더 빨리 가져온다는 점을 인정한다면, 여전히 남는 문제는 '잔여적 차별'이 정말 효율적인가 하는 점이다. 엡스타인은 장기 고용관계가 공식 규범과 비공식 규범, 즉 관계적 계약(relational contracts)에 의해 지배되며, 기업 내부의 선호 다양성이 낮을수록 이러한 규범의 설정과 집행 비용이 줄어든다고 본다. 그래서 일정한 종류의 '정렬(sorting)' 이후 남는 차별은 효율적일 수 있다는 것이다. 그는 또 집단 내 집합적 선택과 지배구조 비용 역시 구성원의 선호 다양성이 작을수록 낮다고 주장한다.

하지만 이러한 주장은 대부분의 맥락에서 사용자 차별을 설명하지 못한다. 실제 설명은 고용주·동료·소비자 사이에 존재하는 악의적 차별 취향에 더 가까운 경우가 많다. 또한 이런 논리는 너무 쉽게 다수의 혐오적 차별을 정당화하며, 이미 신뢰를 잃은 '분리하되 평등하다'는 원리와도 위험하게 연결된다. 설령 취향

기반 차별이나 통계적 차별이 때때로 효율적이거나 경제적으로 합리적이라 하더라도, 그것이 곧바로 합법적이어야 함을 뜻하지는 않는다. 특히 소수집단이 경제에서 차지하는 비중이 작을수록 차별의 부 효과는 그 집단의 소득과 기회에 훨씬 더 큰 타격을 줄 수 있다.

매킨토시는 시장이 특히 과거에 차별받아 온 소수자를 채용하는 문제에서는 지속적 역선택 때문에 균형으로 수렴하지 못할 수 있다고 지적한다. 경쟁시장이 때때로 소수자의 경제적 지위를 향상시킨다는 점을 인정하더라도, 그것은 항상 경제적으로 의미 있는 정도의 잔여 차별을 남긴다. 그리고 그 잔여 차별은 외부효과를 낳고, 무엇보다 인적자본 투자에 영향을 미친다.

차별금지법의 비용과 편익에 대해서는, 규제가 피해자에게 주는 편익이 집행비용을 넘지 못할 수 있다는 비판도 있다. 그러나 첫째, 다수와 함께 규제비용을 분담한다는 비판은 편익이 실제로는 피해자에게 집중된다는 점에서 약하다. 둘째, 차별금지 비용을 피하려고 소수자 노동자를 덜 고용하게 된다는 주장 역시, 그에 수반되는 생산성 손실을 고려하면 쉽게 뒤집힌다.

모든 법에는 비용이 있다. 차별금지법의 상징적이고 실질적인 사회적 편익이 크다 하더라도, 사회가 그 목적을 위해 얼마의 비용을 감수할 의사가 있는지는 중요하다. 이러한 편익은 돈으로 바로 비교하기 어렵지만, 최소한 평가하려는 시도는 필요하다. 예를 들어 충분한 정보를 가진 사람이 차별금지법의 폐지를 받아들이는 대가로 얼마를 요구할지를 통해 그 제도의 생산성 효과를 가늠할 수 있다. 도노휴의 비용-편익 분석을 따르면, 연간 편익이 연간 비용을 초과하기 때문에 차별금지법은 효율성을 증진한다.

추정적 비용을 논할 때는 취향 기반 차별에서의 개인 선호 좌절과 경제적 비용을 구분해야 한다. 또 세 가지 상쇄요인을 놓쳐서는 안 된다. 취향 기반 차별은 생산성을 떨어뜨릴 수 있고, 차별로부터의 자유는 작업환경의 매력을 높일 수 있으며, 통계적 대리변수보다 더 좋은 선발기법에서 얻는 생산성 향상이 그 비용을 충분히 상쇄할 수 있다. 반대로 추정적 편익을 평가할 때는 개인의 경제적 이득뿐 아니라, 지지자들이 누리는 도덕적 이익, 반대자들이 겪는 상징적 손실, 수혜자들의 실제 이득, 편향된 반대자들의 심리적 손실까지 포함해야 한다. 무엇보다 차별금지입법은 공공재적 성격을 강하게 띠므로, 그 편익을 단순한 시장형 규제만으로 최적 수준에서 공급하기는 어렵다.

b. 취향 기반 차별에 대한 규제

경쟁시장이 장기적으로 고용주와 노동자의 취향 기반 차별을 줄일 수 있다 하더라도, 차별금지법은 그 과정을 가속화하고 고용주에게 충분한 정보를 제공한다는 점에서 정당화된다. 더 나아가 잔여 차별이 제 3 자 외부효과와 역선택 동학을 낳는다고 본다면, 규제의 목적은 더욱 강하게 지지된다.

특히 소비자의 취향 기반 차별의 경우에는 규제의 필요성이 더 분명하다. 앞서 보았듯 경쟁시장은 이 형태의 차별을 제거하지 못하며, 오히려 차별적 소비자의 후원을 얻기 위한 경쟁이 차별의 부정적·비효율적 결과를 키울 수 있다. 이 경우 규제는 필수적이다.

c. 통계적 차별에 대한 규제

통계적 차별은 차별 취향이 없어도 발생할 수 있고, 어떤 경우에는 관련 특성의 합리적 대리변수로 사용될 수도 있으므로, 이를 금지하는 규제 비용의 정당화는 취향 기반 차별보다 어렵다. 포스너는 통계적 차별이 때때로 효율적일 수 있다는 점을 인정하면서도, 그렇다고 해서 합법이어야 하는 것은 아니라고 본다. 그는 헌법 사건에서와 비슷한 이익형량 접근을 제안한다.

그럼에도 경제학적 관점에서 보더라도, 인종과 같은 통계적 지표의 사용을 금지하는 차별금지법은 충분히 정당화될 수 있다. 특히 그 사용이 역선택 문제를 낳고, 심지어 실제 생산성 차이를 정확히 반영하는 경우처럼 경쟁압력에 잘 견디는 통계적 차별에서도 사회적 계층화라는 큰 비용을 남기기 때문이다. 더구나 시장만으로는 경쟁시장 안에서도 장기적으로 지속될 수 있는 오류적 통계차별 문제를 해결할 수 있다고 결론 내리는 것은 잘못이다.

결론

법경제학은 그 자체로 규범적 기능을 갖는 것은 아니지만, 시민권과 차별금지법에 관해 그동안 거의 의심받지 않았던 전제들을 다시 생각하게 만들었다는 점에서는 분명한 공로가 있다. 그러나 어떤 입장을 다시 검토한다는 것과 그 제도를 폐지해야 한다는 것은 전혀 다른 문제다.

계약 자유를 옹호하는 경제학적 비판과 차별금지 정책을 어떻게 조화시킬 수 있는가. 먼저, 차별금지법과 계약 자유의 관계는 영미권 차별 논쟁에서 오랜 숙제였다. 최근 법경제학이 차별금지입법을 정면으로 비판하면서 이 쟁점이 다시 전면에 부상했다. 효율성 비판은 사적 자율성과 계약 자유가 핵심 개념이 되는 자유롭고 경쟁적인 시장을 상정하며, 바로 그 시장이 차별의 치료책이 될 수 있다고 본다. 그러나 그 관점에서조차 차별금지법은 두 가지 이유로 경제적 정당성을 가진다. 하나는 비차별 균형의 도래를 앞당긴다는 점이고, 다른 하나는 완전히 자유로운 시장도 제거하지 못하는 해로운 잔여 차별을 막는다는 점이다. 완전히 효율적인 잔여 차별이라는 것은 존재하지 않으며, 따라서 차별금지법을 두고 계약 자유가 비효율적 차별을 제거하고 효율적 차별을 보존하는 것을 부당하게 방해한다고 말할 수는 없다.

오히려 차별금지법에 대한 경제분석은, 경쟁시장이 차별을 제거하는 데 능동적 역할을 할 수 있다는 점을 인정할수록, 자유사회에서 차별금지입법이 왜 정당한가를 묻는 철학적·도덕적 기초가 더욱 중요해진다는 사실을 드러낸다. 사적 차별을 막고 제거하기 위해 국가가 강제력을 행사하고 계약 자유를 제한하는 것이 왜 정당한가 하는 문제 말이다. 앞서 검토한 두 철학적 정당화 가운데서는, 엡스타인의 '파생적' 자유지상주의가 지닌 비일관성을 고려할 때, 자율성 기반 정당화가 훨씬 더 설득력 있고 폭넓은 동의를 얻을 수 있다. 차별금지법은 차별이 개인의 자율성과 가치 있는 선택지 가운데서 선택할 권리에 가하는 해악을 예방하거나 교정하려는 국가의 개입이기 때문에 철학적으로 정당화된다.

그렇다면 이러한 경제적·철학적 고려를 계약이론, 특히 계약 자유 이론과는 어떻게 연결할 수 있을까. 차별금지정책의 자율성 기반 정당화와 긴밀히 연결되어, 현대 계약이론은 보다 적극적인 의미의 계약 자유 개념으로 이동해 왔다. 앞서 언급한 '사회적 시장 이론'은 사적 관계에서의 자율성 가치와, 평등한 기회를 박탈당함으로써 발생하는 해악을 모두 인정한다. 그리고 이러한 해악은 국가의 입법적 개입을 통해 정당하게 시정될 수 있다고 본다.

이런 재해석의 중요한 측면 중 하나는 개인들 사이의 '협력' 관계다. 이제 계약법의 핵심은 개인의 의사에 반하여 계약을 강제하기 위해 타인에 대한 해악을 입증하는 데 있지 않다. 오히려 시장교환에서 신뢰할 수 있고 가치 있는 기회를 확보해 주는 계약제도 자체의 가치가 중심이 된다. 이 관점은 계약법이 단지 기존의 도덕적 관행을 뒷받침할 뿐 아니라, 인종주의 예방과 같은 도덕적 선도 기능도 수행한다는 생각을 반영한다. 이때 계약 체결 여부를 자유롭게 선택할 권리에는 하나의 제한이 들어온다. 즉 시장에서 보다 평등한 기회를 보장하기 위해, 인종을 이유로 계약 체결을 거부해서는 안 된다는 의무가 부과된다.

따라서 현대 차별금지법은 특정 사유를 근거로 계약 체결을 거부할 자유는 당사자에게 허용되어서는 안 된다는 전제 위에서, 계약 자유를 정당하게 제한할 수 있다. 그리고 바로 이 지점에서 '사회적 시장 이론'은 이 글의 원형을 닫는다. 표면적으로는 경제적으로도 철학적으로도 대립하는 것처럼 보였던 차별금지법과 계약 자유를, 보다 넓은 자율성 이론에 따라 계약 자유와 그 요건을 재해석하는 새로운 사회-시장 민감적 계약이론 안에서 조화시켜 주기 때문이다.

주석 및 참고문헌

정확한 서지 정보 보존을 위해 아래 내용은 원문 표기를 유지했습니다.

NOTES * I am grateful to Dr Christopher McCrudden for his invaluable criticisms and suggestions regarding the M.Jur Dissertation of which this article is an elaborated extract. All mistakes however remain mine. 1 Trebilcock, M.J. (1993) The Limits of Freedom of Contract, 188-189. Cambridge: Harvard University Press. 2 On the controversial concept of discrimination: McCrudden, C. (ed) (1991) Antidiscrimination Law, xviii, Aldershot: Dartmouth with further references. 3 For our purposes, 'race' will be understood as shorthand for race and

ethnic origin, ie a group of people which considers itself or is considered as different from others because of inherited and immutable characteristics (Mandla and another v Dowell Lee and another [1983] 2 AC 548, HL). 4 See Gardner, J. (1996) 'Discrimination as Injustice', 16 OJLS 353, 365. 5 See Christie v York Corporation (1940) 1 CLR 81, [SC Canada] and Diaz v Pan American World Airways, Inc, 442 F2d 385 (5th Circ., 1971). 6 Epstein, R. (1992) Forbidden Grounds, The Case Against Employment Discrimination Laws. Cambridge: Harvard University Press. 7 Epstein (1992), 495. See also Epstein/Chemerinsky (1993) 'Should Title VII of the Civil Rights Act of 1964 be Repealed?', 2 Southern California Interdisciplinary U 349; Epstein, R. (1996) 'The Subtle Vices of the Employment Discrimination Laws', 29 John Marshall LRev 575. 8 Writings in contract law hardly mention the controversy, except Trebilcock, 1993, Ch. 9. See also Cheshire/Fifoot/Furmston's (1996) Law of Contract (13th edn), 20. London: Butterworths. See also Atiyah, P. S. (1996) An Introduction to the Law of Contract (5th edn), 106. Oxford: OUP. 9 For an exhaustive account: Atiyah, P. (1979) The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: OUP. 10 Collins, H. (1997) The Law of Contract (3rd edn) 25. London: Butterworths. 11 Atiyah, 1996, 13-15. See however Lochner v New York, 198 US 45 (1905). 12 Raz, J. (1986) The Morality of Freedom. Oxford: OUP. See also Brownsword, R. (1988) 'Liberalism and the Law of Contract', 36 Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy 86; Sunstein, C. (1989) 'Disrupting Voluntary Transactions', in Chapman, J. and Pennock, J. (eds), Markets and Justice, Nomos XXXI, Ch. 10. New York: NYU Press. 13 See Gardner, J. (1989) 'Liberals and Unlawful Discrimination', 9 OJLS 1, 2-3. 14 See Rutherglen, G. (1992) 'Abolition in a different voice', Review, 78 Virginia LRev 1463, 1465. See also Epstein, R. (1985) Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain. Cambridge: Harvard University Press; Epstein, R. (1989) 'The Utilitarian Foundations of Natural Law', 12 Harvard J of L and Public Policy 713. 15 Epstein, 1992, 29-31, 59-72. 16 Rutherglen, 1992, 1466; Epstein, 1992, 99-143. 17 Epstein, 1992, 42, 65-67, 75-76. 18 Epstein, 1992, 15-21; Nozick, R. (1974) Anarchy, State and Utopia, Ch. 7. New York: Basic Books. 19 Epstein, 1992, 21-26; Crespi, G.S. (1992) 'Market Magic: Can the Invisible Hand Strangle Bigotry?', 72 Boston U LRev 991, 994. 20 Epstein, 1992, 11-12, 23. 21 Epstein, 1992, 27.

22 Verkerke, J.H. (1992) 'Free to search', Review, 105 Harvard LRev 2080, 2089. 23 Epstein, R. (1994) 'Standing Firm on Forbidden Grounds', 31 San Diego LRev 1, 8, 18-22; Epstein, 1992, 29 ff.

24 Epstein, 1994, 3, answering Brilmayer, L. (1994) 'Lonely Libertarian: One Man's view of Anti-discrimination Law', 31 San Diego LRev 105, 111. 25 Epstein, 1992, 15-24, 75. 26 Epstein, 1992, 156. 27 Epstein, 1992, 12, 20-24, 505; Verkerke, 1992, 2085-2086. 28 Epstein, 1992, 20, 29-31, 72-76. 29 Koppelman, A. (1996) Antidiscrimination Law and Social Equality, 188. New Haven: Yale University Press: critique of libertarians who as 'closet Rawlsians' focus on the benefits of a competitive and free market to the least well off, in contrast to the historical entitlements theory. 30 Epstein, 1994, 4. 31 Brilmayer, 1994, 109-110. 32 Rutherglen, 1992, 1470-1471; Verkerke, 1992, 2089; Epstein, 1992, 93- 112. 33 Donohue, J. (1992) 'Advocacy versus Analysis in Assessing Employment Discrimination Law', 44 Stanford LRev 1583, 1595. 34 See supra note 11. · 35 Epstein, 1996, 575. 36 Donohue, 1992, 1613; Verkerke, 1992, 2097. 37 Issacharoff, S. (1992) 'Contractual Liberties in Discriminatory Markets', 70 Texas LRev 1219, 1259. 38 See the previously mentioned Gardner, 1989; Gardner, J. (1992) 'Private Activities and Personal Autonomy: At the Margins of Antidiscrimination Law', in Hepple, B. and Szyszcak:, E. (eds), Discrimination: The Limits of Law, 148. London: Mansell; Gardner, 1996; Gardner, J. (1998) 'On the Ground of her Sex(uality)', 18/1 Oxford Journal of Legal Studies 167. 39 Gardner, 1996, 365. 40 Gardner, 1989, 1-3, with references. 41 Gardner, 1996, 365-366; Gardner, 1989, 18. See Rawls, J. (1993) Political Liberalism, 187. New York: Columbia University Press. 42 Gardner, 1996, 355-357, 366. 43 Gardner, 1989, 3-5 and 5-11, with references. 44 Gardner, 1989, 12-15; Gardner, 1996, 362. 45 Gardner, 1996, 366-367. 46 Raz, 1986, 415-418. 47 Gardner, 1998, 179, with references. 48 Gardner, 1989, 17-22; Gardner, 1992, 154-155; Gardner, 1998, 170, referring to Raz, 1986, Ch. 14. 49 Gardner, 1989, 18. 50 Raz, J. (1987) 'Autonomy, Toleration and the Harm Principle', in Gavison, R. (ed), Issues in Contemporary Legal Philosophy, 313. Oxford: OUP; Gardner, 1989, 18-19.

51 Raz, 1986, 412 ff. 52 Gardner, 1989, 19. 293 53 Gardner, 1992, 162-163, referring to the Mandla case (supra note 3). 54 Raz, 1986, 410. 55 See Gardner, 1992, 155-157. 56 See Collins, H. (1987) 'The Decline of Privacy in Private Law', 14/1 J of L and Society 91, 102; Gardner, 1992, 148, 158-167. 57 On freedom of association: Gardner, 1992, 150-151. See also Board of Directors of Rotary Inti v Rotary Club of Duarte, 481 US 537 (1987) and Charter v Race Relations Board, [1973] 1 All ER 512, HL. 58 Gardner, 1998, 168, with references. 59 Gardner, 1992, 163-167, with references. 60 Posner, R.A. (1992) Economic Analysis of Law (4th edn), 12. Boston: Little Brown. 61 Posner, R.A. (1981) The Economics of Justice, 91-92. Cambridge: Harvard University Press. 62 Donohue, J.J. (ed) (1997) Foundations of Employment Discrimination Law, 158. Oxford: OUP. 63 See Epstein, R.A. (1984) 'In Defense of the Contract at Will', 51 U Of Chicago LRev 947; Epstein, R.A. (1983) 'A Common Law for Labor Relations: A Critique of the New Deal Labor Legislation', 92 Yale LJ 1357. 64 See Wilkinson, F. (1994) 'Equality, Efficiency and Economic Progress: The Case for Universally Applied Equitable Standards for Wages and Conditions of Work', in Sengenberger, W. and Campbell, D. (eds), Creating Economic Opportunities: The Role of Labour Standards in Economic Restructuring. Geneva: International Institute for Labour Studies. 65 Strauss, D.A. (1991) 'The Law and Economics of Racial Discrimination in Employment: The Case for Numerical Standards',

79 Georgetown LJ 1619, 1634 [Strauss, 1991]; even Epstein, 1992, 79-87. 66 Donohue, 1997, 183-184. See McAdams, R.H. (1995) 'Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination', 108 Harvard LRev 1003. Contra: Epstein, R. (1995) 'The Status-production Sideshow: Why the Anti-discrimination Laws are still a Mistake', 108 Harvard LRev 1085. 67 See Strauss, 1991, 1621-1622. See for a third type of classification: Donohue, J.J. (1994) 'Employment Discrimination Law in Perspective: Three Concepts of Equality', 92 Michigan LRev 2583, 2585. It should be noted that this twenty-years old classification has never been updated and thus heavily impairs the relevance of the economic analysis. 68 See Becker, G. (1971) The Economics of Discrimination (2nd edn). Chicago: University of Chicago Press. 69 Strauss, 1991, 1621. 70 See Macintosh, J.G. (1987) 'Employment Discrimination: An Economic Perspective', 19 Revue de droit d'Ottawa 275, 280, with further references. 71 Strauss, 1991, 1632-1634; Macintosh, 1987, 300. 72 Macintosh, 1987, 280, with further references. 73 Strauss, 1991, 1632, 1635-1637.

74 Becker, 1971. 75 Macintosh, 1987, 280--281; Epstein, 1992, 302-305; lssacharoff, 1992, 1244. 76 Strauss. 1991, 1632, 1638-1639. 77 Macintosh, 1987. 278-279; Epstein, 1992, Ch. 2. See also Strauss, 1991. 1622. 78 Trebilcock, 1993, 205. 79 Strauss, 1991, 1641-1643. 80 Strauss. 1991, 1640. 81 Strauss, 1991, 1626-1630; Trebilcock, 1993, 199, 205; Macintosh, 1987, 284-295. 82 Macintosh, 1987. 292. 83 Donohue, 1997, 158; Donohue, J.J. (1986) 'Is Title VII Efficient?', 134 U Of Pennsylvania LRev 1411; Posner, R. (1987) 'The Efficiency and the Efficacy of Title VII', 136 U Of Pennsylvania LRev 513; Donohue, J.J. (1987) 'Further Thoughts on Employment Discrimination Legislation: A Reply to Judge Posner'. 136 U Of Pennsylvania LRev 523. 84 Donohue, 1997. 180--182. 85 Donohue, 1986, 1421-1422. 86 Posner, 1992, 652. 87 Epstein, 1992, 77; Donohue, 1992, 1593. 88 See Leech, M.J. (1996) 'Legalizing Employment Discrimination: A Foolish and Dangerous Policy', 29 John Marshall LRev 587, 597. 89 Epstein, 1992, Ch. 3. 61-69; Epstein, 1996, 580--581. 90 See Trebilcock, 1993, 200, with references. 91 Posner, 1992, 651 and 662. 92 Macintosh, 1987, 295-308. 93 See Issacharoff, 1992, 1223 and Sunstein, C. (1991) 'Why Markets Don't Stop Discrimination •. 8 Society. Philosophy and Politics 22. 94 Donohue, 1992, 1599-1607. 95 Posner, 1992, 658. 96 Donohue, 1992, 1606; Donohue, 1997, 185. 97 Macintosh, 1987, 309-310. 98 Macintosh, 1987. 310. 99 Posner, 1992, 662. 100 Macintosh, 1987. 292. 101 Strauss, 1991, 1643. 102 Donohue, 1997, 157; even Posner, 1992, 13, 22-26. See esp. Dworkin, R. (1985) 'Is Wealth a Value?', A Matter of Principle, 237. Cambridge: Harvard University Press. 103 See Donohue, 1992, 1586 and 1611; Strauss. 1991, 1656-1657; Leech, 1996, 612. 104 Collins, 1997, 28-34, who refers to Schroeder Music Publishing Co Ltd v Macaulay, [1974] 1 WLR 1308, HL. 105 See Raz, J. (1982) 'Promises in Morality and Law', Review, 95 Harvard LRev 916, 933-935.

REFERENCES Atiyah, P. (1996) An Introduction to the Law of Contract (5th edn) Oxford: OUP. Atiyah, P. (1979) The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford: OUP. Becker, G. (1971) The Economics of Discrimination (2nd edn) Chicago: University of Chicago Press. Brilmayer, L. (1994) 'Lonely Libertarian: One Man's View of Antidiscrimination Law', 31 San Diego Law Review 105.

Brownsword, R. (1988) 'Liberalism and the Law of Contract', 36 Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy 86. Cheshire/Fifoot/Furmston's (1996) Law of Contract (13th edn) London: Butterworths. Collins, H. (1997) The Law of Contract (3rd edn) London: Butterworths. Collins, H. (1987) 'The Decline of Privacy in Private Law', 14 Journal of Law and Society 91. Crespi, G.S. (1992) 'Market Magic: Can the Invisible Hand Strangle Bigotry?', Review, 72 Boston University Law Review 992. Donohue, J.J. (ed) (1997) Foundations of Employment Discrimination Law, Oxford: OUP. Donohue, J.J (1994) 'Employment Discrimination law in perspective: Three Concepts of Equality', 92 Michigan Law Review 2583. Donohue, J.J. (1992) 'Advocacy Versus Analysis in Assessing Employment Discrimination Law', 44 Stanford Law Review 1583. Donohue, J.J. (1987) 'Further Thoughts on Employment Discrimination Legislation: A Reply to Judge Posner', 136 The University of Pennsylvania Law Review 523. Donohue, J.J. (1986) 'Is Title VII Efficient?', 134 University of Pennsylvania Law Review 1411. Dworkin, R. (1985) A Matter of Principle, Cambridge: Harvard University Press. Epstein, R.A. (1996) 'The Subtle Vices of the Employment Discrimination Laws', 29 John Marshall Law Review 575. Epstein, R.A. (1996) 'Regulatory Sins Versus Market Legacies: A Short Reply to Mr Leech', 29 John Marshall Law Review 617. Epstein, R.A. (1995) 'The Status-Production Sideshow: Why the Antidiscrimination Laws are still a Mistake', 108 Harvard Law Review 1085. Epstein, R.A. (1994) 'Standing Firm on Forbidden Grounds', 31 San Diego Law Review 1. Epstein, R.A. (1994) 'Caste and the Civil Rights Laws: from Jim Crow to Same-Sex Marriages', 92 Michigan Law Review 2456. Epstein, R.A. (1992) Forbidden Grounds, The Case Against Employment Discrimination Laws, Cambridge: Harvard University Press. Epstein, R.A. (1989) 'The Utilitarian Foundations of Natural Law', 12 Harvard Journal of Law and Public Policy 713. Epstein, R.A. (1985) Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain, Cambridge: Harvard University Press. Epstein, R.A. (1984) 'In Defense of the Contract at Will', 51 U Of Chicago LRev 94 7.

Epstein, R.A. (1983) 'A Common Law for Labor Relations: A Critique of the New Deal Labor Legislation', 92 Yale Law Journal 1357. Epstein/Chemerinsky (1993) 'Should Title VII of the Civil Rights Act of 1964 be Repealed?', 2 Southern California Interdisciplinary Law Journal 349. Gardner, J. (1998) 'On the Ground of her Sex(uality)', 18/l Oxford Journal of Legal Studies 167. Gardner, J. (1996) 'Discrimination as Injustice', 16/3 Oxford Journal of Legal Studies 353. Gardner, J. (1992) 'Private Activities and Personal Autonomy', in Hepple, B. and Szyzczak, E. (eds), Discrimination: The Limits of Law?, 148 London: Mansell. Gardner, J. (1989) 'Liberals and Unlawful Discrimination', 9 Oxford Journal of Legal Studies 1. Issacharoff, S. (1992) 'Contractual Liberties in Discriminatory Markets', 70 Texas Law Review 1219. Koppelman, A. (1996) Antidiscrimination Law and Social Equality, New Haven: Yale University Press. Leech, M.J. (1996) 'Legalizing Employment Discrimination: A Foolish and Dangerous Policy', 29 John Marshall Law Review 587. Macintosh, J.G. (1987) 'Employment Discrimination: An Economic Perspective', 19 Revue de droit d'Ottawa/Ottawa Law Review 275. McAdams, R.H. (1995) 'Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination', 108 Harvard Law

Review 1003. McCrudden, C. (ed) (1991) Antidiscrimination Law, Aldershot: Dartmouth. Nozick, R. (1974) Anarchy, State and Utopia, New York: Basic Books. Posner, R.A. (1992) Economic Analysis of Law (4th edn) Boston: Little Brown. Posner, R.A. (1987) 'The Efficiency and the Efficacy of Title VII', 136 University of Pennsylvania Law Review 513. Posner, R.A. (1981) The Economics of Justice, Cambridge: Harvard University Press. Rawls, J. (1993) Political Liberalism, New York: Columbia University Press. Raz, J. (1987) 'Autonomy, Toleration and the Harm Principle', in Gavison, R. (ed), Issues in Contemporary Legal Philosophy, 313 Oxford: OUP. Raz, J. (1986) The Morality of Freedom, Oxford: OUP. Raz, J. (1982) 'Promises in Morality and Law', Review, 95 Harvard Law Review 916. Rutherglen, G. (1992) 'Abolition in a Different Voice', 78 Virginia Law Review 1463. Strauss, D.A. (1991) 'The Law and Economics of Racial Discrimination in Employment: The Case for Numerical Standards', 79 Georgetown Law Review 1619. Sunstein, C. (1994) 'The Anti caste Principle', 92 Michigan Law Review 2410. Sunstein, C. (1991) 'Why Markets don't Stop Discrimination', 8 Society, Philosophy and Policy 22.

Sunstein, C. (1989) 'Disrupting Voluntary Transactions', in Chapman, J. and Pennock, J. (eds), Markets and Justice, Nomos XXXI, Ch. 10 New York: NYU Press. Trebilcock, M.J. (1993) The Limits of the Freedom of Contract, Cambridge: Harvard University Press. Verkerke, J.H. (1992) 'Free to Search', 105 Harvard Law Review 2080. Wilkinson, F. (1994) 'Equality, Efficiency and Economic Progress, The Case for Universally Applied Equitable Standards for Wages and Conditions of Work', in Sengenberger/Carnpbell (eds), The Role of Labour Standards in Economic Restructuring, Geneva: International Institute for Labour Studies.